壹、立法理由

一、§1146Ⅰ：方便一次請求，概括回復，无須個別起訴（批評：實務上§767、1146Ⅰ均一一列舉）

二、§1146Ⅱ：從速確定繼承关係，保障交易安全（批評：已有其他保護第三人規定，且短時效不利真正繼承人資格）

三、統一確定繼承人資格（批評：僅於真正繼承人請求返還時考慮即可）

貳、侵害繼承权

一、意义：繼承既得权＝已為繼承人之权利

1.繼承資格被否定→可由確认繼承权訴訟解決

2.遺產标的物被概括占有→可由§767解決

3.應合併认為係本於繼承人地位請求概括回復被占有之遺產标的物

二、時点

1.SC53台上592例、107台上993：於繼承开始時自命為繼承人而行使遺產上权利

2、戴、棋：不分繼承开始前、後

3.J437：SC53台上492例合憲→僅為侵害態樣之一→繼承开始時或其後有人否认真正繼承人之資格並排除占有

參、性質

一、形成权說（戴炎輝）→以訴請求回復繼承权屬形成之訴

二、集合权說（棋）：係個別之物权請求权之集合，兼確认及給付訴訟性質（批評：J107、§767、§1146Ⅱ時效均不同，若目的同一似无必要）

三、独立权說

1.確认、給付混合請求权說（SC $\underset{\text{形成权說}}{\underline{\text{40台上730例}}}$、53台上1928例、琛、戴東雄、棋）

2.單純給付請求权說（林、史、J771、鼎、胡）

(1)繼承資格之確认僅係判決之先決問題，非訴之聲明之終局标的

(2)可合併提起給付及確认訴訟，亦可於給付訴訟中提起中間確认之訴

(3)J771、林：§1146Ⅱ僅使表見人取得拒絕返還之抗辯权，不影响真正繼承人之資格或已取得之权利

肆、競合（§767 vs §1146）

一、法條競合說（劉得寬）：罹於§1146Ⅱ後原有繼承权即已消失，表見繼承人溯及繼承开始時取得繼承权，真正繼承人无§767（SC 40台上730例—廢、37院解3997）

二、時效相互影响說（戴、史）兩者併存，但§1146係特別請求权，應優先適用→以§767起訴仍得以§1146Ⅱ抗辯

三、自由競合說（黃宗樂、林、郭振恭、詹國器、J437王澤鑑協同意見書、J771、SC90台上464、107台簡上54）

伍、請求权人

一、真正繼承人：§1146Ⅰ被害人＝真正繼承人

二、真正繼承人之繼承人

1.一身專屬說：不得行使（琛、胡、鼎、戴、棋）

2.得繼承說：得代已死亡之人行使（振、史、林）

三、法代（§1146Ⅰ）：此為代理請求，非固有权利，若法代為侵害繼承权人⇒§1086Ⅱ特別代理人

四、遺產管理人（§1184）：若认承认繼承之人非繼承人得向其請求之

五、共同繼承時（§1151）須按 §828Ⅲ $\xrightarrow{準用}$ §821 請求

陸、請求之相对人

一、僭称繼承人：自命為繼承人而占有遺產者

二、表見繼承人：外表上足使人信其為繼承人之人

三、共同繼承人中一人或數人排除他共同繼承人之繼承权而占有遺產（SC 29渝上1340例、1504例）

1、現實占有被侵害之遺產

2、对真正繼承人地位有爭執

四、受让前述人財產之第三人

1、肯定说：恶意第三人若不能請求，則将遷延時日，增加脫產机会⇒保护真正繼承人（戴東雄、37院解3856）

2、否定说：請求要件应為曾占有遺產及对是否為繼承人有爭執，且自有§767及善意規定（楨、鼎、胡、琛、戴、SC 53台上1928例、林）

3、折衷说：限第三人与侵害人立於同一「概括地位」時才能請求⇒個別移轉一部財產時非相对人（史、黃宗樂）

五、受认領子女对第三人：应排除同一順位之其他繼承人已取得之財產（§1069但）（SC 109台簡抗180裁）

柒、行使

一、无限制⇒可訴外請求（通）

二、以訴為之

1、列举返还之遺產

(1) 形成訴訟说—不必列举说（戴炎輝）：訴之目的係回復繼承权

(2) 給付訴訟说—不必列举说（史、林）：得請求侵害人占有之一部或全部返还，无須個別行使

(3) 混合訴訟说—不必列举说（琛）

(4) 混合訴訟说—应列举说（楨）：不过便宜而合併為一訴，仍須列举個別財產权，未列举者，既判力及執行力均不及未列举之財產

(5) 实務—給付訴訟说—应列举说

A、雖不必列举说較合法理，惟操作上窒礙難行

B、給付訴訟之聲明应表明被告所負給付义務之內容⇒未表明將使法院依民訴§249Ⅰ⑥以其訴不合法以裁定駁回之（SC 33上3077例、28渝上1641例）

C、縱勝訴，因无明列執行标的物⇒執行法院无從執行⇒僅具中斷時效之意义，实益不大

2、真正繼承人不知遺產範圍，无法列举（Ger§2027）

(1) §177Ⅱ不法管理 $\xrightarrow{準用}$ §177Ⅰ ⇒恶意僭称繼承人可被真正繼承人主張享有不法管理所生之利益

(2) 類推§173Ⅱ $\xrightarrow{準用}$ §540 ⇒不法管理人与无因管理人負相同報告义務

三、黃詩淳：共有人間僅有遺囑、特留分紛爭時，不適用§1146亦不能行使基於特留分扣減之物上請求权（§767）

捌、時效（§1146Ⅱ）

一、起算時点

1、2年：知悉受侵害時起，非知悉繼承开始

↳无行為能力人以法代知悉起算（SC 29上174例）

2、10年：繼承开始時（效力大於前段之2年）

二、時效性質

1、2年：消滅時效

2、10年

(1) 消滅時效說（通、SC 32上3143例、37院解3842）

史：消滅時效說
棋：除斥期間說

A、文义解釋

B、若解為除斥期間，施§2 形同虛設，因§1146Ⅱ為繼承篇唯一之時效規定

C、比較法（JP、Ger、FR、Swiss）均長於TW ⇒ 應解為消滅時效，使其有中断机会，保护真正繼承人

D、時效完成後，义務人仍得拋棄已完成之時效利益（史）

E、林：應為特殊之消滅時效，无重行起算之可能

(2) 除斥期間說（棋）：不得中断、延長始達短期時效之目的

三、与§767：自由競合說 ⇒ 罹於§1146Ⅱ後仍得行使§767

四、J771：兼顧法安定性，不論动產或不动產行使§767時有§125 15年時效限制（補充J107、J164）

五、罹於時效

1、僅生回復义務人得拒絕給付之抗辯权（SC 29渝上867例）

2、37院解3997、SC 40台上730例—廢：抗辯权行使後真正繼承人与表見繼承人地位互易

↕

3、通、J771

(1) 不因有抗辯权而取得繼承权 ⇒ 須另以時效或善意取得規定為之（戴）

(2) 若对1人已滿2年，对未滿2年之他人仍得請求§1146，繼承权不因時效消滅

玖、拋棄

一、繼承开始前：无效（通、SC 22上2256例），因§1146尚未具体發生，拋棄須客体之存在

二、繼承开始後：有效（通），因繼承权（§1174Ⅰ）、特留分均可拋棄，§1146屬財產权之一种，其拋棄无違公序良俗，无禁止之理

三、效力

1、劉得寬：僭称繼承人取得繼承权

2、戴：使其同繼承人增加應繼分，惟若真正繼承人有明白表示欲使表見繼承人取得繼承权時不在此限

3、林：繼承权係身分权，不得轉让 ⇒ 僭称繼承人无繼承权；真正繼承人仍未喪失遺產所有权並仍須承担繼承債務，應繼分亦應无变动